

業務上の占有者による横領行為に非占有者が加功した場合の罪責について、教授及び学生が次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内に後記アからキまでの【発言】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちのどれか。

【会 話】

教授. 保険会社の保険料集金担当従業員である甲が、同社の従業員ではない知人乙と共謀の上、集金した保険料を横領した事例のように、業務上の占有者に非占有者が加功した場合のそれぞれの罪責について、共犯と身分の観点から、どのようなことが問題になりますか。

学生. 業務上横領罪の成否に関して、同罪は、単純横領罪との関係では(①)であり、他方、非占有者との関係では(②)となりますから、特に乙に対して、何罪が成立するのが問題になります。

教授. 判例ではこの事例はどのような結論になりますか。

学生. 判例は、(③)としています。

教授. 判例の立場に対しては、どのような批判がなされていますか。

学生. 非身分者について罪名と科刑の分離を認めるのは妥当でないという批判がなされています。

教授. この点を克服するための考え方としては、どのようなものがありますか。

学生. 刑法第65条第1項は違法身分について規定し、同条第2項は責任身分について規定していると考え、業務上横領罪については、(④)と捉えた上で、この事例では(⑤)とする見解などがあります。

【発 言】

ア. 占有の受託者という身分があることによって犯罪行為になる構成的身分犯

イ. 業務者という身分があることによって刑が加重・減軽される加減的身分犯

ウ. 占有の受託者たる身分は責任身分、業務者たる身分は違法身分

エ. 占有の受託者たる身分は違法身分、業務者たる身分は責任身分

オ. 刑法第65条第1項により甲には業務上横領罪が、同条第2項により乙には単純横領罪がそれぞれ成立し、甲及び乙は単純横領罪の範囲で共犯となる

カ. 刑法第65条第1項により甲及び乙は業務上横領罪の共犯となり、同条第2項により乙に対しては単純横領罪の刑を科す

キ. 刑法第65条第1項により甲及び乙は単純横領罪の共犯となり、更に同条第2項により甲については業務上横領罪が成立する

1. ①ア ②イ ③カ ④ウ ⑤オ
2. ①ア ②イ ③キ ④ウ ⑤オ
3. ①イ ②ア ③オ ④エ ⑤カ
4. ①イ ②ア ③カ ④エ ⑤キ
5. ①イ ②ア ③キ ④ウ ⑤カ

() には順に、①=イ、②=ア、③=カ、④=エ、⑤=キと入り、正解は肢4となる。

① イが入る

①には、単純横領罪との関係における業務上横領罪の位置づけに関する記述が入る。業務上横領罪は、物の占有が業務上の委託関係に基づくことによって刑が加重される(253条)点で、単純横領罪の加重類型である。よって、①には、イ「業務者という身分があることによって刑が加重・減輕される加減的身分犯」が入る。

② アが入る

②には、非占有者との関係における業務上横領罪の位置づけに関する記述が入る。業務上横領罪は、他人の物の占有者であるとともに、業務者でなければならないという点で、真正身分と不真正身分の組み合わせだった複合的身分犯であるから、非占有者との関係では、他人の物の占有者しか犯せない真正身分犯(構成的身分犯)である。よって、②にはア「占有の受託者という身分があることによって犯罪行為になる構成的身分犯」が入る。

③ カが入る

③には、本事例における判例の結論に関する記述が入る。そして、判例は、本事例と同様に非占有者が業務上横領に加功した場合の非占有者について、「被告人兩名はかかる業務に従事していたことは認められないから、刑法65条1項により同法253条に該当する業務上横領罪の共同正犯として論ずべきものである。しかし、同法253条は横領罪の犯人が業務上物を占有する場合において、とくに重い刑を科することを規定したものであるから、業務上物の占有者たる身分のない被告人兩名に対しては同法65条2項により同法252条1項の通常の横領罪の刑を科すべきものである。」

(最判昭32.11.19、百選I94事件)としている。よって、③には、カ「刑法第65条第1項により甲及び乙は業務上横領罪の共犯となり、同条第2項により乙に対しては単純横領罪の刑を科す」が入る。

④ エが入る

④には、65条1項は違法身分について規定し、同条2項は責任身分について規定していると考えた場合における、業務上横領罪の身分の捉え方に関する記述が入る。まず、違法身分とは、当該犯罪の処罰根拠となる法益侵害を惹起し得る地位をいい、責任身分とは、法益侵害惹起についての責任を加重軽減する地位をいう。そして、単純横領罪における占有者という身分は、252条所定の形態における法益侵害(所有権ならびに法的保護に値する委託関係の侵害)の可能性を限定するものであるから違法身分であると解されている。よって、④には、エ「占有の受託者たる身分は違法身分、業務者たる身分は責任身分」が入る。

⑤ キが入る

⑤には、占有の受託者たる身分は違法身分で、業務者たる身分は責任身分であると捉えた場合における、本事例の帰結に関する記述が入る。そして、65条1項が違法身分の連帯性、同条2項が責任身分の個別性を規定したものとする立場からは、占有の受託者たる違法身分は連帯的に作用することから、業務上横領罪に関与した非占有者についても65条1項により単純横領罪の共犯となる。また、業務者という責任身分は個別に作用することから、業務者については同条2項により業務上横領罪が成立することになる。よって、⑤には、キ「刑法第65条第1項により甲及び乙は単純横領罪の共犯となり、更に同条第2項により甲については業務上横領罪が成立する」が入る。